



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Milano

Seconda sezione Civile

La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Caterina Chiulli	Presidente
dott.ssa Gabriella Anna Maria Schiaffino	Consigliere rel.
dott.ssa Letizia Tomasina Ferrari Da Grado	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **2883/2019** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. RONCORONI TIZIANO elettivamente domiciliato in VIA PLINIO, 3 22100 COMO presso il difensore avv. RONCORONI TIZIANO

APPELLANTE

contro

CP_1 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. MARCINKIEWICZ ANDREA e dell'avv. FRANZINI MARCO (*C.F._3*) VIA CONSERVATORIO, 17 20122 MILANO; , elettivamente domiciliata in VIA CONSERVATORIO, 17 20122 MILANO presso il difensore avv. MARCINKIEWICZ ANDREA

APPELLATA

Oggetto:divisione beni non caduti in successione

CONCLUSIONI

Per parte appellante: Per *Parte_1*

Piaccia alla Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, giudicare:

In via pregiudiziale e cautelare:

sospendere e revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.

Nel merito:

in riforma della sentenza nr. 67/2019 del Tribunale di Como, dichiarare la intrasferibilità dei beni immobili oggetto di divisione ereditaria per cui è causa ai sensi della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite - Cass. Sez. Un. 7 ottobre 2019, n. 25021;

Nel merito in via subordinata:

a) riformare la sentenza nr. 67/2019 del Tribunale di Como disponendo la modifica del progetto divisionale indicato nella decisione impugnata ed adottando il sotto riportato progetto divisionale:

LOTTO 1 in assegnazione a Parte_1 :

Controparte_2

- Part. C.F. **939 sub. 9**

CP_3 (PIANO CP_4)

- Part. C.F. **939 sub. 10**

RIPOSTIGLIO/DEPOSITO (Controparte_5)

- Part. C.F. **939 sub. 11**

AUTORIMESSA (Controparte_6)

- Part. C.F. **939 sub. 12**

CP_7 (Controparte_6)

- Part. C.F. **939 sub. 13**

CP_8 Controparte_9 (Controparte_6)

- Part. C.F. **939 sub. 14**

CP_7 (Controparte_6) ABITAZIONE E BALCONE (PIANO PRIMO)

- Part. C.F. **939 sub. 17**

CP_7 (Controparte_6) BITAZIONE (CP_10)

BALCONE (CP_10)

- copertura piana praticabile (CP_10)

- vano scala, ingresso e disimpegno comune (Controparte_6)

- vano scala, e disimpegno comune (CP_11)

- area di pertinenza all'edificio, di cui alle Part. C.T. **93**

N.B.: particelle gravate da servitù di passaggio carraio e pedonale (vds. grafici tavole n.ri 1-2-3-4);

- Part. C.F. **939 sub. 16**

CANTINE (PIANO SEMINTERRATO) ABITAZIONE (CP_10)

BALCONE (PIANO CP_10 ABITAZIONE (PIANO PRIMO)

- copertura piana (PIANO PRIMO)

- Part. C.T. **406 TERRENO bosco ceduo**

- Part. C.T. **1034 TERRENO semin arbor**

N.B.: la particella 1034 è gravata da servitù di passaggio carraio e pedonale (vds. grafici tavole n.ri 1-2-3-4);

VALORE TOTALE LOTTO "1" € 557.842,25

LOTTO 2 in assegnazione a CP_1 :

Controparte_12

- Part. C.F. **941 sub. 5**

Controparte_13

[...]
- Part. C.F. **941 sub. 4**

Controparte_14

- area di pertinenza dell'edificio, di cui alle Part. C.T. **941, 1619 e 334**

N.B.: la particella 941 è gravata da servitù di passaggio carraio e pedonale (vds. grafici tavole n.ri 1-2-3-4);

- Part. C.T. **1759 Pt_2 seminativo**

Pt_3 la particella è gravata da servitù di passaggio carraio e pedonale (vds. grafici tavole n.ri 1-2-3-4);

- Part. C.T. **329 TERRENO bosco ceduo**

- Part. C.T. **330 TERRENO semin. arbor.**

- Part. C.T. **331 TERRENO bosco ceduo**

- Part. C.T. **332 TERRENO bosco ceduo**

N.B.: particella gravata da servitù di passaggio carraio e pedonale (vds. grafici tavole n.ri 1-2-3-4);

VALORE TOTALE LOTTO "2" € 479.432,04

DETERMINAZIONE CONGUAGLI

LOTTO 1 in assegnazione a Parte_1

VALORE ASSEGNATO € 557.842,25

QUOTA DI PROPRIETA' (1/2) € 518.637,15

Dare € 39.205,10

LOTTO 2 in assegnazione a CP_1

VALORE TOTALE ASSEGNATO € 479.432,04

QUOTA DI PROPRIETA' (1/2) € 518.637,14

Avere € 39.205,10

Il tutto previa verifica tecnica sui reali valori del Lotto 2 stante il grave danno strutturale su di esso gravante

b) riformare la sentenza nr. 67/2019 del Tribunale di Como in punto spese disponendo la compensazione delle spese di I° grado con ripetizione di quanto eventualmente già versato.

Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

In via istruttoria:

chiedesi ammettere consulenza tecnica diretta alla prospettazione di un nuovo progetto divisionale in funzione dello stato di fatto e dei diritti soggettivi di apprezzabile opportunità dei condividenti ma soprattutto in funzione dello stato di imminente crollo strutturale dell'immobile ex opificio.

Disporre perizia tecnica diretta ad accertare lo stato (in) stabilità strutturale del fabbricato opificio quantificandone il valore così come gravemente degradato e visibilmente evidenziato dalle lesioni strutturali di cui alla perizia depositata in atto di citazione d'appello (doc. 4) ed aggravati così come da perizia depositata in questa sede di p.c., nonché i costi per la messa in sicurezza qualora possibile.

Per parte appellata: Per **CP_1**

Previe le declaratorie di legge e del caso,

in via preliminare, in rito: respingersi la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza gravata, per difetto dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. e, comunque, per insussistenza di gravi e fondati motivi;

sempre in via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avversario, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. e/o 342 c.p.c. e/o, comunque, per difetto di interesse ad agire dell'impugnante;

In via principale: rigettarsi l'appello proposto da **Parte_1** tutti i motivi di gravame e tutte le domande proposti da controparte, siccome inammissibili, improponibili e infondati, in fatto e in diritto; per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza di primo grado, il progetto divisionale ivi indicato e le domande proposte da **CP_1** .

In ogni caso: condannarsi l'appellante a rifondere a **CP_1** spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre CPA ed IVA come per legge.

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato *CP_1* conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Como *Parte_1* chiedendo la divisione del compendio ereditario a lei pervenuto nella misura della metà relativo alla successione del coniuge *Persona_1* fratello del convenuto, deceduto il 10 febbraio 2001. Prospettava di essere comproprietaria nella misura indicata degli immobili siti in Inverigo costituiti sia da fabbricati che da terreni censiti al C.T. foglio 9 mappali 334,1619,1759, nonché censiti al NCEU foglio 6, mappali 941,sub 4 e sub 5, nonché di cui ai mappali 939,sub 9,sub 10, sub 11, sub 12, sub 13, sub 14, sub 16, sub 17, nonché di cui al C.T. foglio 9 mappali 329, 330, 331, 332, 406, 940, 1034. In particolare esponeva di non utilizzare da tempo alcuno degli immobili descritti e di voler esercitare il diritto potestativo alla loro divisione qualora comodamente divisibili, nulla opponendo nell'ipotesi in cui controparte avesse richiesto in proprio favore l'integrale assegnazione del compendio ereditario salvo conguaglio all'attrice, non essendo la stessa disponibile a rilevarlo a sua volta integralmente.

Nel giudizio si costituiva *Parte_1* comproprietario nella stessa misura degli immobili, il quale aderiva alla domanda di divisione chiedendo in comparsa di risposta, che, nella formazione dei due lotti, venissero incluse le porzioni da lui attualmente godute di cui ai mappali 939 sub 11 e 16.

Nel corso del giudizio il Tribunale disponeva, ai sensi della previsione di cui all'art 295 cpc, la sospensione del procedimento avendo *Parte_1* instaurato nelle more altro giudizio nei confronti di *CP_1* con riferimento alla prospettata nullità del testamento redatto da *Persona_1* in favore del coniuge.

Esaurito tale procedimento con sentenza definitiva di rigetto di ogni pretesa formulata dall'attore, e riassunto da *CP_1* quello di divisione, il Giudice disponeva ctu al fine di verificare la consistenza e il valore del compendio in comunione, nonché successiva integrazione avendo il convenuto rappresentato l'esistenza di una situazione di precarietà dell'edificio destinato ad opificio ricompreso nell'asse ereditario. All'esito di tali incombenzi, il Tribunale, concessi termini ridotti per le difese finali, tratteneva la

causa in decisione. Emetteva, quindi, ordinanza con la quale, attese le contestazioni svolte dal convenuto, disponeva la rimessione del procedimento in istruttoria al fine di far predisporre un nuovo progetto di divisione, tenuto conto delle censure mosse e delle richieste formulate da questi. Espletata tale ulteriore indagine e fissata udienza di comparizione personale delle parti per definire la lite, *Parte_1* non si presentava all'udienza e, all'esito di essa il Giudice rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni, trattenendo nuovamente la causa in decisione, una volta concessi termini ridotti per le difese finali.

Con sentenza n. 67/2019, pubblicata il 21 gennaio 2019, il Tribunale di Como, prima sezione civile, così statuiva:

- a) disponeva lo scioglimento della comunione, assegnando il lotto I, di colorazione rosa nella planimetria redatta con ctu integrativa all'allegato n.2.1 a *CP_1* e il Lotto n. 2 di colorazione celeste a *Parte_1*
- b) poneva a carico di entrambe le parti in misura uguale, l'onere delle spese necessarie per la realizzazione delle opere funzionali all'esecuzione del progetto divisionale,
- c) condannava *Parte_1* al versamento in favore di *CP_1* del conguaglio pari ad euro 85.687,51 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- d) disponeva la costituzione di servitù di passo a carico dei seguenti beni mapp. 1034 (in assegnazione al lotto 2, *Parte_1*, mappali 939 e 940 (enti comuni) mappali 1759 e 941 (in assegnazione al Lotto 2, *Parte_1*, ed a favore dei beni costituenti i Lotti 1 e 2 (i cui dati catastali sono richiamati in parte motiva), secondo il tracciato indicato nella tavola 3 allegata all'elaborato peritale integrativo depositato il 22 giugno 2018;
- e) poneva le spese di ctu, liquidate come da separati decreti, a carico integrale di parte convenuta;

f) condannava parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquidava in euro 565,00 per spese ed in euro 19.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15% iva e cpa, come per legge;

g) disponeva la trascrizione presso i RRI di Como a norma degli artt. 2646 c.c e ss.

Avverso all'indicata decisione interponeva impugnazione *Parte_1* chiedendone la parziale riforma. Nel giudizio si costituiva *CP_1* insistendo per la conferma della sentenza. Non essendo possibile conciliare la lite le parti precisavano le rispettive conclusioni il 15 ottobre 2020. Concessi termini per le difese finali, la Corte, con ordinanza del 3 marzo 2021, all'esito della camera di consiglio, disponeva la rimessione della causa in trattazione, ai sensi della previsione di cui all'art 101 comma secondo c.p.c. al fine di consentire alle parti di interloquire in ordine ad eventuali profili di improcedibilità della divisione, attese le statuizioni della Corte di Legittimità a sezioni unite n 25021 intervenute il 7 ottobre 2019 successivamente alla sentenza di primo grado.

All'esito del contraddittorio instaurato sul punto, le parti precisavano nuovamente le rispettive conclusioni nelle forme della trattazione scritta, all'udienza del giorno 26 aprile 2022, all'esito della quale, concessi termini di giorni cinquanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche, la Corte tratteneva la causa in decisione.

Nel presente giudizio parte appellante articola due motivi di censura.

Con il primo lamenta l'erroneità, l'insufficienza e l'omessa motivazione della sentenza impugnata con specifico riferimento alla mancata motivazione del Giudice in ordine alle osservazioni svolte dal consulente dell'appellante alle conclusioni raggiunte negli elaborati, non avendo a suo avviso il ctu fornito alcuna risposta a riguardo. Assume, quindi, come in violazione dei principi operanti in tema di divisione il Giudice non abbia considerato in modo adeguato lo stato di fatto esistente tra le parti all'epoca, statuendo ingiustificate assegnazioni, così come avrebbe palesemente violato il principio secondo il quale nei limiti del possibile i conguagli dovrebbero essere contenuti e non

incrementati, con conseguente violazione della previsione di cui all'art 727 c.c per il quale la divisione dovrebbe essere attuata secondo criteri di omogeneità delle quote assegnate ad ogni comproprietario.

Con il secondo motivo di censura critica, quindi, la sentenza per aver essa condannato l'appellante all'integrale pagamento, sia delle spese di ctu che di divisione, ravvisando la sussistenza di uno spirito dilatorio da questi posto in essere per impedire la divisione stessa, giustificandosi, al contrario, attesa la natura del giudizio, la compensazione integrale delle spese relative all'intera procedura.

Tanto premesso, avendo la difesa di CP_1 svolto alcune eccezioni preliminari chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, sia per violazione della previsione di cui all'art 342 cpc, sia per mancanza di interesse al gravame in capo all'appellante, ed avendo a sua volta la difesa di Parte_1 all'esito del contraddittorio instaurato dal Collegio a seguito della pronuncia a sezioni unite della Corte di Cassazione n 25021 del 2019, prospettato l'improcedibilità della divisione, la Corte osserva quanto segue.

Entrambe le eccezioni preliminari articolate da parte appellata devono essere disattese.

Quanto alla prima, è sufficiente rilevare, diversamente da come argomentato da CP_1 [...], che nell'atto introduttivo l'appellante ha indicato le singole parti della decisione oggetto di censura, nonché le ragioni di essa e le modifiche auspiccate, perché risulti di tutta evidenza l'infondatezza dell'eccezione sul punto articolata. Analoghe conclusioni si impongono con riferimento alla seconda eccezione. A differenza di quanto prospettato dall'appellata, risulta indubbio l'interesse dell'appellante ad una modifica della prima decisione non appena si consideri come essa abbia accolto solo in parte le sue pretese, limitatamente all'assegnazione in suo favore solo di un appartamento ubicato all'interno della palazzina di Inverigo, e non dell'intero fabbricato, con la conseguenza che, fermo restando la necessità di verificare la fondatezza o meno di quanto censurato, l'impugnazione proposta non è priva di interesse mirando ad una sostanziale modifica della sentenza di primo grado.

Con riguardo, quindi, all'eccezione di improcedibilità articolata da Parte_1

[...] in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, si deve anzitutto disattendere la doglianza di controparte che ha eccepito la novità e, pertanto, l'inammissibilità di tale richiesta preliminare. E', infatti, sufficiente rilevare come essa tragga origine dal provvedimento del Collegio che ha invitato le parti a prendere posizione sulle eventuali conseguenze derivanti dalla statuizione della Corte di Legittimità in tema di scioglimento di una comunione relativa ad edifici abusivi, perché risulti evidente l'infondatezza dell'eccezione di novità svolta, tanto più ove si tenga presente come qualsivoglia eventuale improcedibilità debba essere dichiarata, se del caso, anche d'ufficio in presenza di un atto dispositivo inerente ad immobili abusivi.

Nel merito la Corte ritiene, peraltro, che, nel caso di specie, all'esito di una serie di valutazioni, la divisione in contestazione non sia improcedibile. per le ragioni che seguono.

Dall'esame della prima ctu redatta dal geometra Persona_2 (depositata il 28 marzo 2017) emerge che la comunione in contestazione ricomprende anche parte di un fabbricato adibito ad opificio, sicuramente abusivo in quanto realizzato senza alcuna concessione edilizia ovvero altro analogo provvedimento. In particolare, tale abusività concerne la realizzazione di un porticato aperto avente destinazione a deposito, un manufatto con struttura in lamiera zincata coibentato destinato a laboratorio nonché la realizzazione di una tettoia portico ad uso deposito. Le porzioni immobiliari così descritte risultano essere state fatte oggetto di ordinanza di demolizione, in quanto abusive, n 57 del 13 luglio 1992, e sono state graficamente rappresentate dal ctu negli allegati 2A e 2B della relazione del marzo 2017. L'esperto (pagg18-19) ha, quindi accertato come la restante parte dell'opificio sia stata fatta, invece, oggetto di nulla osta n 12 del 26 gennaio 1967 e n 2/1968 dell'8 febbraio 1968 per trasformazione ed ampliamento di fabbricato esistente. Da ultimo ha precisato: *“per quanto riguarda la restante parte dell'opificio, sulla base delle pratiche edilizie esaminate, sempre in contraddittorio con i CTP e sentito il tecnico comunale, è stata riscontrata una lieve*

difformità dello sviluppo del profilo del prospetto Sud del manufatto. Anche per questa difformità il CTU ha predisposto un elaborato grafico con la rappresentazione dello sviluppo sia di quanto realizzato, sia di quanto autorizzato (all 2C)

Come ben evidenziato sul grafico la superficie realizzata è inferiore a quanto autorizzato ed inoltre la difformità non muta la conformazione dell'opificio. Sono state riscontrate inoltre lievi difformità interne che riguardano la disposizione del vano scala ed i servizi igienici al piano terra, mentre al piano primo è stata riscontrata la mancanza di un piccolo disimpegno previsto nel primo servizio igienico. ..Le lievi difformità riscontrate nella restante parte dell'opificio sono regolarizzabili mediante la presentazione di SCIA in sanatoria.”

Ciò precisato, la Corte ritiene che nel caso di specie all'esito dell'esame degli atti e della giurisprudenza di Legittimità non sia ravvisabile alcuna ipotesi di improcedibilità dell'originaria domanda.

Secondo la giurisprudenza formatasi sul punto “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art 46 del dpr 6 giugno 2001, n 380 e dall'art 40 comma 2, della legge 28 febbraio 1985 n 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art 713 c.c. sotto il profilo della possibilità giuridica e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass.Sez. U. 7 ottobre 2019, 25021;). La Corte di Legittimità con altra fondamentale decisione sempre a sezioni unite ha statuito che “la nullità comminata dall'art 46 del DPR n 380 del 2001 e dagli artt.17 e 40 della L n,47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c. di cui costituisce una specifica

declinazione, e deve qualificarsi come nullità testuale con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile proprio a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato” (Cass.SU 22 marzo 2019, 8230;).

In particolare nella parte motiva di detta statuizione, poi integrata, quanto alla inclusione di ogni atto di scioglimento sia della comunione ordinaria che ereditaria nell'ambito degli atti dispositivi *inter vivos* a seguito della pronuncia successiva in precedenza richiamata, si è precisato come non sia ipotizzabile la sanzione della nullità della divisione in presenza di idonea dichiarazione di titolo abilitativo all'edificazione, e ciò a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato nell'atto medesimo, e ciò per la ragione che tale profilo esula dal perimetro della sanzione di nullità. La Corte di Legittimità ha, infatti, evidenziato come in presenza di difformità sostanziale tra titolo abilitativo enunciato nell'atto e costruzione, l'acquirente non sarà esposto all'azione di nullità ma possa solo soggiacere alle sanzioni previste a tutela dell'interesse generale connesso alle prescrizioni della disciplina urbanistica.

Orbene, nel fare doverosa applicazione dei principi enunciati con riguardo alla fattispecie in esame, non pare dubitabile come la natura certamente abusiva di parte degli edifici oggetto della comunione in contestazione non possa rilevare nel caso concreto avendo il ctu chiarito fin dal suo primo elaborato di non aver in alcun modo ricompreso nei due lotti formati gli edifici medesimi, rappresentati in verde nella planimetria predisposta, pertanto rimasti estranei alla divisione ed ancora da considerarsi in comunione tra le parti.

Con riferimento, quindi, alle lievi difformità descritte in precedenza dall'esperto, si deve evidenziare come riguardando esse esclusivamente leggere difformità dell'eseguito rispetto a quanto oggetto di titolo abilitativo, non consegua ad esse alcuna sanzione di improcedibilità della divisione rilevando dette incongruenze, attese le argomentazioni svolte dalla Corte di Legittimità, non già sotto il profilo della nullità dell'atto di scioglimento per mancanza di un titolo abilitativo, ma solo sotto quello del tutto differente dell'applicabilità di eventuali sanzioni amministrative, fermo restando la piena validità della divisione relativa a immobili non abusivi ma solo realizzati in misura lieve in maniera difforme rispetto a quanto autorizzato.

All'esito delle valutazioni esposte si impone, conclusivamente, il rigetto dell'eccezione di improcedibilità della divisione articolata da *Parte_1* con conseguente necessità di un esame nel merito delle singole doglianze da questi articolate nell'impugnazione, che la Corte ritiene di esaminare congiuntamente atteso il comune tema da esse trattato, una volta fatte le seguenti precisazioni.

A fronte della domanda originaria di scioglimento della divisione articolata da *CP_1* [...], nella quale detta parte non manifestava alcuna preferenza in ordine all'assegnazione in suo favore di beni determinati, non abitando più in loco dopo la scomparsa del coniuge, ed affermava al contempo di essere disponibile anche ad una eventuale assegnazione, nel caso di non comoda divisibilità del compendio, dell'intero in favore del convenuto, questi nella comparsa di costituzione chiedeva esclusivamente l'assegnazione in proprio favore, in quanto immobile costituente la sua abitazione familiare, degli edifici censiti ai mappali 939 sub 11 e 16 corrispondenti ad un locale autorimessa ubicato all'interno della palazzina di Inverigo, e ad un appartamento sviluppato su due piani censito come mappale 939 sub 16. Avendo il ctu nel primo progetto di divisione attribuito entrambi detti immobili a *CP_1*, assieme ad altri, nell'ambito del Lotto I, assegnando in favore del convenuto, all'interno della palazzina di Inverigo, l'appartamento censito sub 14 con la cantina annessa, senza così condividere le osservazioni mosse dal consulente di parte *Parte_1* che argomentava in

favore dell'assegnazione dell'intera palazzina al medesimo, avendo l'esperto ritenuto la correttezza del suo progetto di divisione che teneva presente le contenute necessità del convenuto il cui nucleo familiare ben si poteva trasferire in detto appartamento con assegnazione di altro posto sopra il laboratorio destinato ad opificio, ai figli, il Giudice disponeva integrazione dell'elaborato In particolare con ordinanza 26 febbraio 2018 in motivazione rilevava che il convenuto aveva contestato il progetto di divisione nella parte in cui lo privava dell'appartamento in cui esso dimorava con il proprio nucleo familiare attribuendolo all'attrice e gli assegnava un diverso appartamento allo stato disabitato, e richiamava quanto argomentato sul punto dal ctu che aveva fatto riferimento alle necessità di contenere i conguagli. Il Tribunale, quindi, richiamata la giurisprudenza formatasi in tema di divisione ex art 727 c.c., con particolare riguardo alla facoltà del giudice di tenere conto dell'interesse dei condividenti, valorizzando anche fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, considerando lo stato occupazionale attuale degli immobili in comunione, riteneva che, non avendo alcuna parte contestato la circostanza secondo la quale *Parte_1* risiedeva con il coniuge nell'appartamento censito sub 16, e che un eventuale maggior conguaglio derivante da una differente assegnazione non sarebbe risultato irragionevole, una volta tenuto conto di tale stato di occupazione, disponeva che il ctu procedesse ad un nuovo progetto divisionale che tenesse conto di ciò.

A seguito di tale statuizione il ctu predisponendo nuovo progetto divisionale fatto proprio dal Tribunale e in questa sede censurato.

A fronte di dette risultanze, diversamente da come criticato dall'appellante, si deve affermare anzitutto come l'esperto nell'interpretare l'ordinanza in questione in alcun modo ne abbia tradito lo spirito, riducendo l'oggetto delle sue indagini all'assegnazione a *Parte_1* solo dell'appartamento dal medesimo direttamente utilizzato con il coniuge, e non già dell'intera palazzina quale immobile occupato di fatto da tutta la sua famiglia ivi compresi i figli. Ed, invero, come chiaramente precisato in sentenza dallo stesso Tribunale, occorre escludere sul punto qualsivoglia travisamento del tenore del quesito

ad opera dell'esperto, così come non è ravvisabile alcuna errata motivazione a riguardo da parte del Giudice. Il Tribunale, infatti, ha ribadito la correttezza dell'interpretazione data al suo quesito dall'esperto, in tali termini circoscritti, corrispondendo a quanto stabilito nell'ordinanza. Oltre a ciò molteplici elementi inducono comunque il Collegio a ritenere corretta la formulazione del quesito nei termini indicati. Il riferimento da parte di *Parte_1* alla conservazione dello stato occupazionale dei luoghi in sede di divisione con specifico ed esclusivo riguardo solo all'appartamento censito sub 16 ben emerge non appena si consideri come fin dalla comparsa di costituzione di primo grado ogni richiesta di assegnazione in proprio favore del compendio in comunione fosse stata ben circoscritta dal medesimo esclusivamente a detto appartamento e non già all'intero fabbricato, non avendo in alcun modo dedotto di aver da sempre utilizzato assieme ai figli addirittura tutta la palazzina. A riguardo tale asserito utilizzo, allegato per la prima volta solo in sede di osservazioni alla ctu del giugno 2017, non solo è smentito proprio dalle sue richieste iniziali ma è rimasto del tutto privo di prove. Non è emerso dagli atti in alcun modo siffatto stato occupazionale generale dell'intero edificio, senza poi considerare che il fatto stesso, del tutto incontestato, secondo il quale l'appartamento sub 14 inizialmente assegnato al medesimo, fosse pacificamente disabitato, conferma ulteriormente come l'odierno appellante, diversamente da come argomentato, non avesse l'utilizzo dell'intera palazzina e di tutti gli appartamenti in essa insistenti, pari a 4, con conseguente necessità, in tale ipotesi, di tutelare anzitutto in sede di divisione tale stato di fatto. Al contrario, come non contestato e da lui stesso affermato fin dall'atto di costituzione, emerge dalle sue medesime prospettazioni come l'appellante occupasse all'epoca solo l'appartamento effettivamente poi a lui assegnato di cui al mappale 939 sub 16.

Consegue a tali emergenze, diversamente da come censurato al punto sub c del primo motivo, che in alcun modo il Tribunale nella sentenza impugnata ha omesso di considerare lo stato occupazionale degli immobili avendo, anzi, ben tenuto presente le prospettazioni di *Parte_1* in ordine alla circostanza secondo la quale la sua abitazione

familiare era costituita solo dall'appartamento indicato, sviluppato su due piani e non da altri.

Uguualmente non ha pregio l'ulteriore censura sub b) del primo motivo con specifico riferimento alla prospettata omessa risposta da parte del ctu ad una articolata serie di osservazioni svolte dal suo ctp, con la conseguenza che, attesa tale carenza, sarebbe affetta da nullità anche la decisione che, ad avviso dell'appellante, si sarebbe limitata a richiamare genericamente le conclusioni espresse dall'esperto senza colmare le lacune nelle quali questi era caduto.

Procedendo all'esame delle singole censure a riguardo articolate, e fermo restando il potere della Corte di integrare con idonea motivazione, eventuali carenze della sentenza impugnata, il Collegio ritiene che correttamente il Tribunale ha ricompreso nel lotto I, assegnato a CP_1, anche l'unica autorimessa presente nella palazzina di Inverigo, censita sub 11, non essendo condivisibile sul punto la doglianza dell'appellante. Ed, invero tale assegnazione trova ragionevole giustificazione nella circostanza secondo la quale il Tribunale, avendo ritenuto corretta l'assegnazione in favore dell'odierna appellata dei restanti tre appartamenti della palazzina, ha considerato che dovesse spettare alla stessa anche l'unica autorimessa ivi presente ben potendo Parte_1 usufruire per il posteggio, degli ampi spazi esterni alla palazzina stessa a lui assegnati. Sul punto si rileva che lo stesso ctu, investito da tale critica, con particolare riguardo ad un asserito deprezzamento che l'appartamento assegnato all'appellante avrebbe subito non godendo di autorimessa, non ha mancato di precisare come alcun deprezzamento fosse in realtà ipotizzabile, ben potendo l'appartamento usufruire di spazi esterni destinati a posteggio dei veicoli anche essi assegnati a detta parte.

Ed, ancora, deve essere disatteso il lamentato eccessivo frazionamento della palazzina a seguito del progetto di divisione fatto proprio dal Tribunale, in base al quale, sono stati assegnati a CP_1 tre appartamenti di varie metrature ed uno solo a Parte_1 nonché tre cantine alla prima ed una sola al secondo e due locali ripostiglio in favore della stessa. A riguardo si osserva che tale assegnazione non appare illogica o irrazionale

non appena si consideri come a **Parte_1** siano stati assegnati l'intero opificio (nella parte non abusiva) e l'ampio appartamento ad esso sovrastante, al fine di contenere i conguagli. Sul punto occorre evidenziare che essendo destinato detto immobile nella parte posta al piano terra ad un uso industriale (risulta pacifico che era stato in precedenza concesso in locazione da parte dei fratelli **Parte_1** alla **Org_1** tra loro stessi costituita) detta assegnazione appare del tutto coerente con l'eventuale prosecuzione di tale attività nel futuro, anche tramite soggetti terzi da parte del medesimo appellante, residente nelle immediate vicinanze. Ed ancora deve essere disattesa la censura svolta con riguardo all'eccessività dei costi derivanti dal frazionamento della palazzina secondo i criteri fatti propri dal Tribunale, frazionamento che imporrebbe a carico dell'appellante la realizzazione di una nuova centrale termica da collocare all'interno dell'unica cantina a lui assegnata e con conseguente, a suo avviso, inutile ulteriore esborso di somme per la creazione di un nuovo impianto idraulico ed elettrico per consentirne l'uso.

Sul punto è sufficiente osservare come tali profili di critica non siano stati formulati all'epoca in sede di elaborato peritale neppure ad opera del consulente dell'odierno appellante che non ha in alcun modo indicato in quale misura tali costi sarebbero eccessivi, perché risulti l'inconsistenza di dette critiche del tutto generiche e nuove.

Da ultimo, sempre nell'ambito delle censure mosse da **Parte_1** con riferimento all'assegnazione, per lui ingiustificata, dell'opificio con sovrastante appartamento, questi ha prospettato l'erroneità anche di tale decisione in quanto fondata su una valutazione del tutto astratta dell'immobile stesso che non terrebbe in alcun modo conto dello stato di grave dissesto se non di pericolo di imminente crollo dell'intero edificio, come attestato, sia dalla concorde richiesta di entrambe le parti in primo grado di integrazione di ctu con nomina di un esperto che verificasse la staticità dell'immobile, sia in considerazione delle ulteriori produzioni effettuate nel presente grado dal medesimo per evidenziare la pericolosità crescente dell'intera struttura tale da giustificare quantomeno un supplemento di indagini tecniche.

Le doglianze esposte devono essere disattese. Premesso che con specifico riguardo alle produzioni nel presente grado di due elaborati stragiudiziali del luglio 2019 e del giugno 2020 non è ravvisabile, diversamente da come eccepito dall'appellata, la violazione della previsione di cui all'art 345 cpc, non appena si consideri come esse non siano qualificabili come documenti nell'accezione di tale norma, integrando mere allegazioni difensive, come tali prive di autonoma valenza probatoria (in termini da ultimo Cass sez. II, 19 gennaio 2022,1614; Cass 20347/2017;) si devono nel merito confermare anche sul punto le conclusioni all'epoca espresse dal ctu. L'esperto, nella relazione integrata depositata in data 27 novembre 2017, dopo essersi avvalso dell'ausilio di un ingegnere strutturista nella persona dell'ing. *Persona_3* facendo riferimento al sopralluogo effettuato anche con la partecipazione dello stesso ctu, presso l'immobile in contestazione il 12 ottobre 2017, ebbe ad affermare come dall'esame delle foto scattate nell'occasione rispetto alla documentazione fotografica allegata alla relazione dal consulente di parte convenuta, non emergessero ulteriori ammaloramenti rispetto a quelli rappresentati nelle foto stesse. L'esperto, pertanto, condivideva quanto valutato dall'ausiliario ingegnere, con riguardo alla sicura risalenza nel tempo delle cause che avevano determinato il quadro fessurativo effettivamente riscontrato presumibilmente connaturato alla costruzione e ai successivi interventi di suo ampliamento. Escludeva, pertanto, la necessità di ulteriori indagini consistenti, in ipotesi, in un periodo di monitoraggio delle fessure stesse mediante posa di strumentazioni ottiche od elettroniche quali fessurimetri. Conseguenza a tali valutazioni l'infondatezza delle censure mosse anche sul punto dalla parte appellante non integrando le due relazioni stragiudiziali fonti di prova idonee a giustificare ulteriori approfondimenti.

Parte_1 ha, quindi, censurato la decisione anche con riferimento alla ritenuta sproporzione dei conguagli disposti in sentenza che comporterebbero un eccessivo esborso a suo carico. In particolare assume che rispetto all'importo di soli euro 39.205,10, che dovrebbe corrispondere a controparte qualora la Corte aderisse al progetto di divisione da lui predisposto e precisato in atti, il Giudice facendo proprie le

conclusioni elaborate dal consulente, ha quantificato il conguaglio a suo carico nel maggior importo di euro 85.687,51 in palese violazione dei principi che dovrebbero regolare l'individuazione degli immobili da assegnare alle parti all'atto della formazione dei lotti.

La Corte ritiene che anche la censura esposta non meriti accoglimento. Non pare infatti dubitabile come l'indubbio incremento delle somme poste a carico di *Parte_1*

[...] sia stato determinato dalla richiesta del medesimo di diventare assegnatario anche dell'appartamento censito sub 16 posto su due piani, di valore nettamente superiore a quello dell'appartamento sub 14 inizialmente a lui assegnato nel primo progetto di divisione, senza poi considerare che, sempre in accoglimento di ulteriori sue osservazioni, il ctu ha assegnato al medesimo anche l'area esterna limitrofa a detto appartamento di cui alla partita CT 1034, circostanza che ha ulteriormente fatto lievitare il conguaglio.

All'esito delle valutazioni esposte si deve, infine, disattendere la censura svolta sub punto a) del primo motivo con riguardo alla prospettata violazione dei criteri di cui all'art 727 c.c.. Il Tribunale, infatti, ha assegnato i lotti, secondo il progetto di divisione elaborato dal ctu nel giugno del 2018, tenendo conto, diversamente da come criticato, di criteri di omogeneità degli immobili nel rispetto delle quote di ciascuna parte nonché dello stato di fatto relativo all'utilizzo di essi (Cass.2017 n 29733; Cass 2008 n 16219).

Si impone, pertanto, il rigetto del primo motivo con riferimento a tutti i profili di censura in esso articolati

Procedendo, quindi, alla valutazione del secondo motivo di gravame, inerente il riparto delle spese di lite, la Corte osserva quanto segue.

Il Tribunale ha motivato in ordine alla condanna di *Parte_1* all'integrale pagamento sia delle spese di tutte le ctu e delle relative integrazioni, nonché delle spese di controparte nel giudizio di divisione, evidenziando il contegno processuale da questi assunto, finalizzato, a detta del Giudice, a procrastinare la durata dello stesso *“impedendo di fatto la conclusione del procedimento attraverso il meccanismo*

dell'approvazione del progetto predisposto dal ctu (che ha avuto l'adesione solo della parte attrice) e fatto proprio da questo giudice”.

A fronte di tale statuizione parte appellante evidenzia, al contrario di non aver in alcun modo assunto una condotta defatigatoria atteso che fin dalla propria costituzione non si era opposta alla divisione richiesta da **CP_1**, aveva svolto contestazioni che avevano determinato la decisione dello stesso Giudice di rimettere le parti in istruttoria disponendo un nuovo progetto di divisione, così come evidenzia, quanto all'ulteriore indagine effettuata, finalizzata a verificare lo stato di conservazione e di stabilità del fabbricato destinato ad opificio e del sovrastante appartamento, come sul punto la stessa controparte avesse manifestato piena adesione in relazione a tali approfondimenti

La Corte ritiene che la censura svolta meriti accoglimento.

Secondo la costante giurisprudenza di Legittimità “nei procedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione” (Cass.sez.II, 24 gennaio 2020, 1635; Cass.sez. I, 8 ottobre 2013, 22903;).

Facendo applicazione di tali principi nella vicenda processuale in esame occorre evidenziare come fin dall'atto di costituzione **Parte_1** non si sia opposto alla divisione chiesta da controparte, chiedendo solo che fossero ricompresi nel suo lotto determinati beni. In accoglimento di tali richieste il Tribunale, dopo una prima ctu, ne ha disposto una nuova che tenesse in conto, in parte, delle censure articolate da questi in sede di osservazioni del proprio consulente con ciò mostrando di non considerare pretestuose le richieste articolate. Ed, ancora, si rileva che l'indagine tecnica disposta per verificare le condizioni di staticità dell'opificio e dell'appartamento ad esso sovrastante è stata richiesta concordemente da entrambe le parti. A fronte di tali dati, diversamente da come argomentato in sentenza, non è ravvisabile una condotta dilatoria

e pretestuosa dell'odierno appellante per non aver alla fine aderito al secondo progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico d'ufficio, non presentandosi all'udienza a ciò finalizzata. Le ragioni di tale comportamento infatti sono state poi illustrate dalla sua difesa che ha argomentato sotto svariati profili, per quanto nel merito non condivisibili, svolgendo considerazioni non pretestuose, in ordine alle ragioni della mancata approvazione del progetto nuovamente elaborato dall'esperto che non corrispondeva alle richieste e alle aspettative dell'appellante. Da ultimo si osserva, diversamente da come argomentato da CP_1 , che l'aver instaurato Parte_1 [...] nelle more del giudizio di primo grado altro procedimento che ha determinato la sospensione ex art 295 cpc del presente, non può essere considerata circostanza dirimente attestante la pretestuosità dell'iniziativa stessa, valutazione non evincibile dal solo esito che ne è derivato, di rigetto di tutte le pretese svolte in tale differente sede nella quale, peraltro, sia in primo grado che in secondo grado, è stato escluso qualsivoglia profilo di pretestuosità e di temerarietà del giudizio.

All'esito delle valutazioni esposte, la Corte ritiene conclusivamente di dover, pertanto, riformare la decisione impugnata con riguardo al capo che ha disposto la condanna dell'odierno appellante al pagamento di tutte le spese di lite di controparte nonché delle spese delle ctu espletate, risultando, al contrario, che la procedura azionata è stata svolta, così come le indagini tecniche, nel comune interesse di entrambe le parti, spese che devono essere poste a carico della comunione in parti uguali, attese le quote paritarie dei contendenti.

Procedendo da ultimo alla liquidazione delle spese processuali inerenti al presente grado, osserva la Corte che, in considerazione dell'accoglimento del gravame solo in minima parte, avendo il Collegio confermato tutte le statuizioni inerenti le assegnazioni dei lotti nei termini disposti dal Tribunale, si giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado tra le parti nella misura di un quarto, con condanna dell'appellante, attesa la sua prevalente soccombenza, al pagamento della restante parte in favore dell'appellata nei termini liquidati in dispositivo, tenuto conto dei criteri di cui

al DM 37 del 2018, in relazione alle attività difensive effettivamente esplicate e del valore del procedimento, nei limiti della nota spese depositata.

P . Q . M .

La Corte d'Appello di Milano

seconda sezione civile definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

in parte l'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *CP_1*

[...] e per l'effetto in

RIFORMA

parziale della sentenza n 67/2019 emessa dalla prima sezione del Tribunale di Como, pubblicata il 21 gennaio 2019

PONE

a carico delle parti in pari misura le spese di primo grado nonché le spese di tutte le ctu e delle relative integrazioni;

CONFERMA

nel resto la sentenza impugnata;

CONDANNA

parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di parte appellata nella misura di tre quarti e, pertanto, condanna *Parte_1*

[...] al pagamento dell'importo di euro 5175,00 per compensi oltre contributo spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;

COMPENSA

tra le parti le spese processuali del presente grado nella restante misura;

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022; .

Il Presidente

dott.ssa Maria Caterina Chiulli

Il Consigliere rel.

dott.ssa Gabriella Anna Maria Schiaffino